

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0060750-56.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WILLEN ALVES RIBEIRO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Tatiana Vieira Guerra**

Vistos.

WILLEN ALVES RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº 8069/90 porque, no dia, horário e local, indicados na denúncia, nesta Capital, agindo em concurso com o adolescente *Matheus Ferreira dos Santos*, trazia consigo, para entrega a terceiros, as drogas descritas na denúncia (cocaína, "crack" e "maconha"), sem autorização legal, corrompendo o menor acima referido, com ele praticando o crime.

O réu foi notificado e, desacolhidos os argumentos expostos na defesa preliminar escrita, a denúncia foi recebida, o acusado foi citado pessoalmente e, na audiência de instrução, debate e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o douto Representante do Ministério Público requereu a procedência parcial da ação, com a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 33, c.c. o art. 40, VI da Lei nº 11.343/06, enquanto a ilustre Defensora Pública pediu a absolvição, por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios legais.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o breve relatório.

D E C I D O.

A acusação é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Com efeito, a absolvição do acusado não é possível, porque as provas, colhidas sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o réu trazia consigo e vendia as drogas apreendidas, confirmada a natureza pelo exame pericial realizado (fls. 97/99).

Ao ser interrogado, sob o crivo do contraditório, o réu negou os fatos e alegou que estava na casa da namorada e saiu para almoçar quando, então, foi detido pelos policiais. Disse que está preso por outro processo em que foi acusado por tráfico, mas que aquela prisão também foi forjada.

Ocorre que os policiais civis que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, detalharam a ocorrência e trouxeram melhores elementos de convicção para formação da certeza positiva de que os fatos ocorreram como narrados na denúncia. Ambos confirmaram que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e que foram até lá e fizeram campana por cerca de 30 minutos, há mais ou menos 40 metros de distância, de onde puderam observar o réu vendendo drogas para usuários. Contaram que os usuários se aproximavam, entregavam o dinheiro para o menor de idade e o réu era quem entregava a droga. Quando foram abordados, as drogas estavam no bolso do réu, em porções individuais, e o dinheiro estava com o menor, em notas trocadas. Disseram que no local o réu admitiu o tráfico, mas que na delegacia o menor acabou dizendo que toda droga era dele, afim de inocentar o réu.

Ocorre que inexistente motivo idôneo para descrédito ou desqualificação aos testemunhos dos Policiais, porque nada nos autos indica tenham alterado a verdade dos fatos em prejuízo do acusado, preso em flagrante delito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A simples condição de Policial, responsável pela segurança pública não é motivo para desqualificação de seu testemunho que se mostrou coerente às demais provas.

Ressalte-se que, conforme salientado pelo i. Representante do Ministério Público, deve ser considerada a causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei nº 11.343/06, a qual restou perfeitamente configurada, já que o menor Matheus, com quem foi encontrado o dinheiro da venda, foi visto pelos policiais com o réu, vendendo as drogas, embora em juízo tenha dito que estava vendendo as drogas sozinho no dia dos fatos.

Portanto, a versão do acusado restou isolada nos autos, sem nenhum amparo, ao contrário das provas produzidas pela acusação, que foram convincentes e comprovaram que este cometeu o delito previsto no **art. 33, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06**, prejudicado o delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Provada a existência material do tráfico de drogas, em todos os elementos do tipo penal, e autoria atribuída ao acusado, inevitável a condenação, passo à dosagem da pena, com observância ao método trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

Na primeira fase de fixação das penas, verifico que a culpabilidade, entendida como reprovabilidade ao agente pela conduta, não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na segunda etapa da dosagem, verifico que o acusado tinha menos de 21 anos na data dos fatos, mas mantenho a pena no patamar acima fixado, observada a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, já que o réu é primário, sem antecedentes criminais, e nada nos autos indica a dedicação exclusiva às atividades criminosas ou que integre organização criminosa e fixo a pena em 01 ano e oito meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Ainda na terceira etapa, tendo em vista a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei, aumento a pena do réu em 1/6 (um sexto) e fixo-a, definitivamente, em **01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 193 dias-multa.**

Estabelecida a quantidade da pena, impõe-se a definição da intensidade, com verificação da constitucionalidade da norma do art. 44, da Lei nº 11.343/06, ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e também a do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado.

Quis a nova Lei de Drogas aperfeiçoar a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico, ao permitir a redução das penas, em até 2/3, aos primários, de bons antecedentes, que não se dediquem às atividades criminosas, nem integrem organização criminosa.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Distinção há muito reclamada pelos aplicadores do Direito, tem por motivação a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas.

Com a distinção, reconheceu atenuada a culpabilidade – repita-se, entendida não só como fundamento e limite da pena, mas também como reprovação ao agente pelo crime cometido –, resultante do menor desvalor da conduta desviante do traficante ocasional e, com isso, o legislador concretizou o comando inserto na Constituição da República, art. 5º, inc. XLVI, de individualização da pena.

Em obediência a mencionado princípio, o legislador infraconstitucional está vinculado ao direito fundamental do condenado, de que sua pena seja particularizada, não só na qualidade (reclusão ou detenção) ou quantidade da resposta penal, mas também na intensidade, vale dizer, na verificação de necessidade do regime inicial mais gravoso ou se a pena pode ser resgatada sem ingresso no ambiente deletério do cárcere.

Nesse passo, reconhecida a culpabilidade atenuada, porque o legislador da Lei nº 11.343/06 entendeu ser de menor desvalor a conduta do traficante ocasional e concedeu-lhe extraordinária diminuição de até 2/3 das penas cominadas, não é razoável, nem proporcional, impor-lhe o início do cumprimento da pena em regime fechado ou vedar-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vedação a afrontar os princípios da individualização da pena, por igualar condenados considerados desiguais pela própria lei que os distinguiu, e da proporcionalidade, impeditivo de excesso, a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

exigir do Poder Judiciário concretizar a resposta penal, com observância às circunstâncias judiciais, dentre elas a culpabilidade – reprovabilidade ao agente pelo desvalor da conduta –, para estabelecimento da pena cominada, quantidade, regime e substituição, tudo conforme disposto nos artigos 59, do Código Penal.

Inevitável o reconhecimento da invalidade da norma proibitiva do início de cumprimento da pena em regime diverso do fechado e da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela violação ao devido processo legislativo, por não observar os comandos constitucionais de individualização da pena, porque, embora tenha cominado para o mesmo crime penas diversas em razão das condições pessoais dos acusados, com reconhecimento do excesso de penas ao primário, exige-lhe igual recolhimento ao cárcere, em regime fechado, a afrontar também o princípio da proporcionalidade.

Não se pretende assumir poderes legislativos, mas, a aproximação do Direito Penal ao Direito Constitucional, implica interpretar as normas penais ao influxo da Constituição da República para verificação da validade daquelas normas que, inevitavelmente, devem conter os direitos fundamentais, além de serem proporcionais e razoáveis às relações humanas, princípios impeditivos de excessos, da pena desnecessária.

Como ensina Luigi Ferrajoli, com a positivação dos direitos fundamentais nas Constituições, a validade das normas infraconstitucionais não é verificada apenas pela observância ao processo legislativo – parlamento competente e procedimento típico –, mas, necessariamente pelo seu conteúdo, que deve albergar os valores positivados na Constituição e, em caso de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

rompimento, deve ser considerada materialmente inválida e sem efetividade.

Assim é porque: "A sujeição do juiz à lei não é de fato, como no velho paradigma juspositivista, sujeição à letra da lei, qualquer que seja o seu significado, mas sim sujeição à lei somente enquanto válida, ou seja, coerente com a constituição. E a validade já não é, no modelo constitucional-garantista, um dogma ligado à mera existência formal da lei, mas uma sua qualidade contingente ligada à coerência – mais ou menos opinável e sempre submetida à valoração do juiz – dos seus significados com a constituição. Daí deriva que a interpretação judicial da lei é também sempre um juízo sobre a própria lei relativamente à qual o juiz tem o dever e a responsabilidade de escolher somente os significados válidos, ou seja, compatíveis com as normas constitucionais substanciais e com os direitos fundamentais por ela estabelecidos." (O Direito como sistema de garantias. In: "O novo em Direito e Política". Org. José Alcebíades de Oliveira Júnior. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997, p. 100-1).

No mesmo sentido é a advertência de Alberto Silva Franco:

"O Juiz e a Constituição devem ter, em verdade, uma relação de intimidade: direta, imediata, completa. Há um nível de cumplicidade que os atrai e enlaça. Na medida em que, de maneira explícita ou implícita, dá-se a positividade constitucional aos direitos fundamentais da pessoa humana, estabelece-se, ao mesmo tempo, um sistema de garantias com o objetivo de preservá-los. O Juiz passa a ser o garantidor desse sistema. Não pode, por isso, em face de violações ou de ameaças de lesão aos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, permanecer num estado de inércia ou indiferença ou mesmo admitir que o legislador infraconstitucional se interponha


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

indevidamente entre ele e a Constituição." ("Crimes Hediondos", 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 71).

Acolhido pela Constituição da República de 1988, ainda que não expressamente nela apontado, mas inferido pela contextualização dos direitos fundamentais nela positivados, o princípio da proporcionalidade constitui adequado instrumento para verificação da razoabilidade de determinada norma legal, da qual é exigível moderação, equilíbrio ao sentido comum, adequação às relações humanas e nunca resultar da vontade arbitrária do legislador, atributos não verificados na enorme diferença de tratamento na vedação de regime inicial menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a recomendar a adequação – pelo Poder Judiciário, guardião dos direitos fundamentais – do meio empregado (pena) ao fim almejado (prevenção e repressão ao crime).

É desproporcional e irrazoável (até irracional) tratar de modo igual, pela mesma intensidade da pena – sempre em regime inicial fechado –, aos que a lei distinguiu com menor quantidade da pena, pois a dosimetria da resposta penal não se cinge apenas à quantidade, mas também ao estágio inicial de resgate, progressão ao mais brando, possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão de sua execução, fixados sempre com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para definição da pena necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, como recomenda o art. 59, do Código Penal, em sua parte final.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Com essa convicção, resultante da interpretação da norma infraconstitucional ao influxo da Constituição da República, consideradas, no caso em tela, as circunstâncias judiciais favoráveis, o **regime inicial será o ABERTO**, que deve ser estabelecido com observância às circunstâncias judiciais, conforme determina o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o regime inicial deve ser adequado à quantidade da pena, que no presente caso permite o estabelecimento do regime aberto, porque o acusado não é delinqüente contumaz, como pode ser inferido nos autos.

Neste sentido não se pode olvidar do entendimento sumulado pelo E. Supremo Tribunal Federal de que "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Súmula STF nº 718) e também de que "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula STF nº 719).

Atendidas as condições previstas art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, **substituo a pena privativa de liberdade** por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal.

Pena privativa de liberdade superior a um ano, deve ser aplicada, também, 10 dias-multas, cumulada com a pena pecuniária originária.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e condeno WILLEN ALVES RIBEIRO, qualificado nos autos, por infração ao art. 33, “caput”, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a pena de **01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão**, para início no **regime aberto**, em caso de conversão, que substituo por prestação de serviço à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 204 dias-multa (194 dias-multa cominado no tipo penal e 10 dias-multa pela substituição), no valor mínimo legal.

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, **autorizo a incineração**, preservada pequena porção da para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial. Nos termos do disposto no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, **declaro perdido o dinheiro apreendido** com a acusada, em favor da União, a ser revertido diretamente ao FUNAD, oficiando-se.

Facultada a interposição de recurso em liberdade, porque primário, inexistente prova de necessidade da prisão provisória e pela pena e substituição aplicadas. Com o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados.

TATIANA VIEIRA GUERRA

Juíza de Direito

São Paulo, 16 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**